

1500620-04.2020.8.26.0400

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... a efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD).

Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500620-04.2020.8.26.0400 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 26 de agosto de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500620-04.2020.8.26.0400

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES e outro

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Guilherme Henrique de Oliveira Marques e Nilda Oliveira e Silva Marques, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) e art. 35, caput, da LD (fls. 152/154).

Determinou-se o processamento (fls. 158/161).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 260 e 312), apresentou resposta escrita (fls. 286/288 e 315/316). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021 (fls. 317/319) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 407 e 409).

Em audiência (fls. 410/411 [TA]), foram inquiridas três testemunhas arroladas em comum e outra pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, argumentando que, em relação à parte processada Guilherme Henrique de Oliveira Marques, estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado previsto apenas no art. 33, caput, da LD e a autoria delitiva, porém, em relação à parte processada Nilda Oliveira e Silva Marques, não existe prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (v. TA).

II – DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, há alegações preliminares.

A primeira...

Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, "proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida; 'coisas achadas ou obtidas por meios criminosos' (art. 240, § 1º, b, do CPP); 'instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos' (art. 240, § 1º, c, do CPP); 'armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso' (art. 240, § 1º, d, do CPP); 'objetos necessários à prova de infração ou à defesa do autuado' (art. 240, § 1º, e, do CPP); 'cartas, abertas ou não, destinadas ao autuado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato' (art. 240, § 1º, f, do CPP); e 'qualquer elemento de convicção' (art. 240, § 1º, h, do CPP)."

Com efeito, "a mera alegação genérica de 'atitude suspeita' é insuficiente para a lícitude da busca pessoal" (STJ – Sexta Turma – RHC n. 158.580-BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, V.U., j. 19/04/2022).

No caso dos autos, todavia, o comportamento da parte processada Guilherme Henrique de Oliveira Marques, por ocasião dos fatos, foi explicado, com detalhes, pelos agentes do Estado (o contexto fático anterior à busca pessoal, que será dissertado no item seguinte, permitiu a conclusão acerca da ocorrência fundada de ocultação de objetos ilícitos), de sorte que reputo lícita a diligência estatal.

A segunda...

Nos termos do art. 5º, LVI, da CF, "são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos", "devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais" (art. 157, caput, do CPP).

"São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas – doutrina da árvore dos

frutos envenenados (fruits of the poisonous tree doctrine, doutrina de los frutos del árbol venenoso) –, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente – teoria da fonte independente (independent source limitation) – das primeiras" (art. 157, § 1º, do CPP).

De acordo com o disposto art. 5º, XI, da CF, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Houve fundada suspeita de que uma das partes processadas, por ocasião dos fatos, em razão do seu comportamento (que será dissertado no item seguinte), ocultava consigo objetos ilícitos (art. 240, § 2º, do CPP) (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/06), o que, no entender deste magistrado, legitimou a intervenção estatal.

Com efeito, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de infração penal no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

"A investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado configura exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais" (STJ – Quinta Turma – AgRg no HC n. 734.423-GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, V.U., j. 24/05/2022).

Os moradores consentiram o ingresso dos agentes do Estado (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502975-84.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANDRÉ CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 11/11/2021, p. 04).

Daí a licitude e constitucionalidade da diligência (APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pleito defensivo de nulidade do processo por ilegalidade e abuso de poder na investigação. Inocorrência. Acusados surpreendidos em estado de flagrância. Situação que torna lícito o ingresso de policiais no recinto doméstico. Inteligência do art. 5º, XI, da CF. [TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001110-76.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. PÉRICLES PIZA, V.U., j. 5/12/2016]).

O caso era de flagrante delito (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003002-49.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO, V.U., j. 31/08/2021, p. 03 ["Ademais, ainda que não houvesse autorização, foram encontradas duas garruchas para as quais 'o acusado' não tinha registro {drogas, no presente caso dos autos}. Portanto, havia na hipótese flagrante delito, que também justifica, por si só, o ingresso na residência. Portanto, não há necessidade de se obter ordem judicial para se adentrar na residência do acusado, pelos motivos expostos, dado o permanente estado de flagrante, razão pela qual se afasta a preliminar."]; TJSP – 12ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500785-51.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JOÃO MORENGHI, V.U., j. 03/03/2023, p. 04: ["... não houve ilegalidade ou ilicitude na busca realizada no domicílio do apelante, uma vez que os policiais militares ao receberem denúncia anônima, informando que estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes na residência no local dos fatos, tinham fundadas razões para ingressar na residência, o que tira o caráter ilícito de tal diligência."]; TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022,

p. 03/06), ademais.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é, em parte, procedente.

Certa a materialidade objetiva e parcial de um dos contextos fáticos descritos na denúncia, pela leitura dos boletins de ocorrência (fls. 15/18 [BO]), do auto de exibição e apreensão (fls. 19/20 [AEA]), dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 60/62) e definitivo (fls. 335/336 [LPTox]), ressalvado o elemento subjetivo (dolo), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue, com ressalva, a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha André Francisco Andrioli, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 05), que: "os indiciados são conhecidos pela prática de tráfico na cidade de Olímpia e na data de hoje receberam várias informações anônimas dando conta de que hoje receberiam uma certa quantidade de maconha. As informações ainda davam conta de que Guilherme vendia a droga fracionada em frente a sua residência e que quando acabava era sua genitora quem o abastecia e para disfarçar a prática, soltava pipa. QUE com base nas informações montaram força tarefa com outras viaturas e canil e foram até o local indiciado. No local encontraram Guilherme na frente da residência soltando pipa, na companhia da esposa Jéssica que segurava seu filho de 8 meses no colo. Guilherme foi abordado e em busca pessoal encontraram uma trouxa de maconha no bolso de sua bermuda. Simultaneamente sua genitora, que se encontrava na porta da residência foi abordada, com ela nada foi encontrado, porém ao ser informada sobre a denúncia a mesma disse que na residência não havia nada de ilícito e autorizou a entrada no imóvel. Foi feita uma busca preliminar e com a chegada do canil foi feita a busca com o cão Dag que encontrou no quarto de Guilherme, dentro de uma caixa, que estava com umas peças de roupa, um bloco de maconha e debaixo do colchão uma trouxinha de maconha. Indagados separadamente, ambos disseram que a droga era de propriedade de Guilherme, mas para seu uso, já que ele disse ser usuário. Já a esposa de Guilherme relatou aos policiais que seu marido vende a droga, sendo que uma pessoa que leva pra ele, mas que não sabe o nome dessa pessoa, relatando ainda que há tempos ele pratica o tráfico e a mãe o ajuda, Jéssica ainda entregou aos policiais a quantia de R\$ 515,00 (quinhentos e quinze reais) dizendo que tratava-se de dinheiro provenientes do tráfico. Inicialmente Jéssica também foi abordada, mas com ela nada foi encontrado. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos indiciados, sendo ambos conduzidos até este Plantão Policial." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Reinaldo Marques de Souza, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "os indiciados são conhecidos pela prática de tráfico na cidade de Olímpia e na data de hoje receberam várias informações anônimas dando conta de que hoje receberiam uma certa quantidade de maconha. As informações ainda davam conta de que Guilherme vendia a droga fracionada em frente a sua residência e que quando acabava era sua genitora quem o abastecia e para disfarçar a prática, soltava pipa. QUE com base nas informações montaram força tarefa com outras viaturas e canil e foram até o local indiciado. No local encontraram Guilherme na frente da residência soltando pipa, na companhia da esposa Jéssica. Guilherme foi abordado e em busca pessoal encontraram uma trouxa de maconha no bolso de sua bermuda. Simultaneamente sua genitora, que se encontrava na porta da residência foi abordada, com ela nada foi encontrado, porém ao ser informada sobre a denúncia a mesma disse que na residência não havia nada de ilícito e autorizou a entrada no imóvel. Foi feita uma busca preliminar e com a chegada do canil foi feita a busca com o cão Dag que encontrou no quarto de Guilherme, dentro de uma caixa, que estava com umas peças de roupa, um bloco de

maconha e debaixo do colchão uma trouxinha de maconha. Indagados separadamente, ambos disseram que a droga era de propriedade de Guilherme, mas para seu uso, já que ele disse ser usuário. Já a esposa de Guilherme relatou aos policiais que seu marido vende a droga, sendo que uma pessoa que leva pra ele, mas que não sabe o nome dessa pessoa, relatando ainda que há tempos ele pratica o tráfico e a mãe o ajuda, Jéssica ainda entregou aos policiais a quantia de R\$ 515,00 (quinhentos e quinze reais) dizendo que tratava-se de dinheiro provenientes do tráfico. Inicialmente Jéssica também foi abordada, mas com ela nada foi encontrado. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos indiciados, sendo ambos conduzidos até este Plantão Policial." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Jessica Nascimento Barreto Lopes, que é companheira do acusado, declarou, perante a autoridade policial (fls. 07), que: "é esposa de Guilherme Henrique de Oliveira Marques, quanto aos fatos tratados nestes autos esclarece que se sentiu coagida pelos policiais militares após os mesmos dizerem que ela ficaria sem o filho, pois o entregariam no Conselho Tutelar e não deseja declarar mais nada." Em Juízo, esclareceu, na oportunidade, que: "Os agentes do Estado não pediram autorização para entrar na casa."

A testemunha Augusto de Jesus Peres, que é conhecido dos acusados, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em síntese, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

* Sr.^a Nilda Oliveira e Silva Marques:

A acusada foi ouvida pela autoridade policial (fls. 11/12).

Negou a prática criminosa.

A oitiva foi assistida por Advogados.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava no seu quarto, quando, de repente, os membros da Polícia Militar apareceram. O motivo e os fins da diligência foram mencionados. Questionada, desconhecia a existência de drogas na casa. Sem pedir autorização, os agentes do Estado começaram a realizar busca domiciliar. Durante a busca domiciliar, os agentes, com o auxílio do cão policial (cão polícia), localizaram, no quarto do seu filho (coacusado), drogas. Chamaram-na de 'porca' e suja'. Não tinha conhecimento das drogas encontradas. Não possui câmeras de monitoramento em sua casa. Seu filho (coacusado) é usuário de maconha desde os 16 (dezesseis) anos de idade e, atualmente, está trabalhando registrado. Não gosta dos membros da Polícia Militar (todos). Por causa do modo de operação policial deles em relação à interrogada e aos seus filhos."

* Sr. Guilherme Henrique de Oliveira Marques:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 09/10).

Negou a prática criminosa.

A oitiva foi assistida por Advogados.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava a soltar pipa com o seu filho em frente à sua residência, quando os membros da Polícia Militar apareceram. Abordaram-no. Não trazia consigo nada de ilícito. Questionado, guardava, para consumo pessoal, drogas (maconha), confirmou. Sem pedir autorização, os agentes do Estado adentraram a sua

casa. Durante a busca domiciliar, os agentes, com o auxílio do cão policial (cão polícia), localizaram, no seu quarto, as drogas. A senhora sua mãe (coacusada) não tinha conhecimento das drogas encontradas. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

Pois bem.

Em capítulos distintos, disserto.

2.1.1Do tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "importar" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "exportar" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado), "remeter" (mandar; enviar; recomendar; fazer entrega; expedir; encaminhar; destinar), "preparar" (aprontar; arranjar; obter [um corpo qualquer] por meio de composição ou decomposição; compor; dosear; urdir; maquinar; pôr em condições de servir; predispor), "produzir" (dar origem a; causar; fabricar), "fabricar" (produzir na fábrica; manufaturar, preparar; inventar; engendrar), "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "vender" (alienar; ceder por certo preço; trocar por dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expor à venda" (apresentar; mostrar), "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebat; transpor), "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "prescrever" (receitar; ministrar), "ministrar" (prestar; fornecer; aplicar), "entregar" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo específico [pela interpretação contextual]) ou "fornecer" (promover; abastecer; guarnecer; ministrar; proporcionar ou ministrar o necessário a) "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 33, caput, da LD, diferentemente do disposto nos arts. 28, caput (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), e 33, § 1º, III (utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com o seu consentimento), da LD, não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 4.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. BACILA, Carlos Roberto; RANGEL, Paulo. Comentários penais e processuais penais à lei de drogas. – 1.ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 7.ª edição – São Paulo: Atlas, 2004. MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 – nova lei de drogas. – 4.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio de. Lei antidrogas anotada – comentários à lei n. 11.343/2006. – 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009. GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice, CUNHA, Rogério Sanches, OLIVEIRA, William Terra de. Lei de drogas comentada. 3.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008), referendado pela

jurisprudência (STF – Primeira Turma – Habeas Corpus 69.806-GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 03; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), de que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, exige-se a vontade de participar da produção e da circulação de drogas (a intenção de comercializar drogas ilícitas).

Não se exige, todavia, a exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106).

Valho-me, pois, dessa explicação.

* Da acusada Nilda Oliveira e Silva Marques:

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante."

Por outras palavras, o ônus da prova incumbe ao autor da ação penal, quanto ao fato constitutivo de seu direito (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05).

A denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva (aspecto subjetivo), mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte [aspecto objetivo]) (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0004887-69.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, V.U., j. 12/06/2022, p. 12 ["... os elementos colhidos a esse título autorizam a condenação do agente, porque os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo."]; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500531-44.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 24/06/2022, p. 08), esclareço.

E, nesse aspecto, o Ministério Público (Parquet), posto (apesar de) alegar, não demonstrou a prova incriminadora (contexto fático constitutivo do seu direito).

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face da acusada pela prática do contexto fático previsto no art. 33, caput, do CP (tráfico ilícito de drogas), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC n. 300.212/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ - 5ª Turma - HC n. 286.582/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ - 5ª Turma - HC n. 353.232/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

No presente caso dos autos, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente a conduta (ação) imputada inicialmente à acusada e o nexo de causalidade entre esta (conduta) e o objeto do contexto fático processada (ou seja, as drogas localizadas e apreendidas), pontífico.

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

* Do acusado Guilherme Henrique de Oliveira Marques:

No entender deste magistrado, sem modificar a descrição do contexto fático contido na denúncia, atribuo, nos termos do art. 383, caput, do CPP, definição jurídica diversa (art. 28, caput, da LD).

E, assim, delibero sobre o contexto fático descrito na inicial.

Nos termos do art. 28, caput, da LD, "quem adquirir, guardar, 'ter' em depósito, transportar ou 'trazer' consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura a infração penal de porte ilícito de drogas para consumo pessoal.

O tipo penal, vejam, é "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebatado; transpor) ou "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "para consumo pessoal" (elemento subjetivo específico), "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]) "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 28, caput, da LD, diferentemente do disposto no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), descreve elemento subjetivo específico do tipo.

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, "a prova da alegação incumbirá a quem a

fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante."

Por outras palavras, o ônus da prova incumbe ao autor da ação penal, quanto ao fato constitutivo de seu direito (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05).

A denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva (aspecto subjetivo), mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte [aspecto objetivo]) (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0004887-69.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, V.U., j. 12/06/2022, p. 12 ["... os elementos colhidos a esse título autorizam a condenação do agente, porque os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo."]; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500531-44.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 24/06/2022, p. 08), esclareço.

E, nesse aspecto, o Ministério Público (Parquet), posto (apesar de) alegar, não demonstrou a prova incriminadora (contexto fático constitutivo do seu direito).

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face do acusado pela prática do contexto fático previsto no art. 33, caput, do CP (tráfico ilícito de drogas), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC n. 300.212/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ - 5ª Turma - HC n. 286.582/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ - 5ª Turma - HC n. 353.232/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

Diferentemente do contexto previsto no art. 28 da LD.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 - Anexo Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha).

No entender deste magistrado, o contexto fático conhecido e provado (o acusado, por ocasião dos fatos, trazia consigo e guardava drogas indevidamente) não autoriza, por indução, concluir-se pelo elemento subjetivo descrito na denúncia (vontade de participar da produção e da circulação de drogas [intuito mercantilista]), o que caracterizaria o crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD).

Trata-se de dado elementar duvidoso.

Nessa perspectiva, os agentes de segurança pública, os quais têm o meu respeito e consideração, não trouxeram, ao serem inquiridos em Juízo, dados suficientes

de que as drogas, no caso vertente, destinavam-se ao consumo alheio (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005997-69.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. IVO DE ALMEIDA, V.U., j. 20/05/2019; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000163-02.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 7/06/2018; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003239-20.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. NEWTON NEVES, V.U., j. 08/08/2019).

Ao contrário, há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente a existência da infração penal de porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), seja pela observação forense do que ordinariamente acontece (*quod plerunque accidit*), seja pelas circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo e guardava, para consumo pessoal, as drogas apreendidas (AEA), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

De rigor, pois, a desclassificação criminal.

Eis o meu convencimento.

2.1.2 Da associação para o tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 35, caput, da LD, "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 'da Lei de Drogas'", configura o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "associarem-se" (reunirem-se, juntarem-se, com ânimo de associação, de caráter duradouro e estável) "duas ou mais pessoas" (plurissubjetividade) "para o fim de praticar" (elemento subjetivo específico [finalidade associativa]), "reiteradamente ou não" (habitualidade ou eventualidade executiva), "qualquer dos crimes" apontados com taxatividade pela Lei de Drogas (finalidade associativa).

O que diferencia o crime de associação criminosa específica do tráfico ilícito de drogas (art. 35, caput, da LD) do concurso de pessoas (art. 29 do CP) é o elemento subjetivo (*animus*) dos sujeitos ativos do crime.

Exige-se, para a configuração do crime de associação criminosa, a demonstração concreta do vínculo de estabilidade e permanência (associatividade), diferentemente do concurso de pessoas.

Não é suficiente a união ocasional, eventual e episódica.

Para determinar se a reunião era, ou não, eventual, o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias comportamentais dos sujeitos ativos do crime (critério objetivo), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama dos sujeitos ativos (odioso critério subjetivo) (STJ - Sexta Turma - AREsp 1.790.656-SC - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04)

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência

e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não se exige, para a configuração deste crime autônomo, a efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD).

Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante."

Por outras palavras, o ônus da prova incumbe ao autor da ação penal, quanto ao fato constitutivo de seu direito (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05).

A denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva (aspecto subjetivo), mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte [aspecto objetivo]) (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0004887-69.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, V.U., j. 12/06/2022, p. 12 ["... os elementos colhidos a esse título autorizam a condenação do agente, porque os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo."]; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500531-44.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 24/06/2022, p. 08), esclareço.

E, nesse aspecto, o Ministério Público (Parquet), posto (apesar de) alegar, não demonstrou a prova incriminadora (contexto fático constitutivo do seu direito).

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face dos acusados pela prática do contexto fático previsto no art. 35, caput, da LD (associação para o tráfico ilícito de drogas), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC n. 300.212/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ - 5ª Turma - HC n. 286.582/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ - 5ª Turma - HC n. 353.232/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

No presente caso dos autos, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente o caráter associativo da convergência de vontades (animus manendi, intenção de permanecer, ânimo associativo) de se praticar um número indefinido de crimes de tráfico ilícito de

drogas (art. 33, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 22/01/2020, p. 06), como, por exemplo (verbi gratia), a habitualidade do contato dos acusados (periodicidade), a confluência dos diálogos (correspondência) e o conteúdo das comunicações (thema).

Não existe prova suficiente (bastante, necessária) de que se tratava de reunião estável e permanente (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. PÉRICLES PIZA, V.U., j. 12/08/2019, p. 11).

O contato (interação) dos acusados, em que pese a relação familiar de coabitação (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501130-17.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 10/05/2021, p. 06/07 [... nada se investigou sobre mais do que a coautoria, não sendo bastante a mera suspeita de associação permanente, ainda que se tome em consideração o fato de os dois estarem praticando o tráfico de drogas no âmbito familiar."]), era meramente ocasional ou episódico.

Não era um verdadeiro pacto associativo, acerto.

Não está evidente a intenção de reiteração delituosa.

Descaracterizada, pois, a associação criminosa específica.

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 28, caput, da LD.

Consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União (art. 1º, parágrafo único, da LD).

Em outras palavras, dependência – física ou psicológica – é o estado de quem não consegue desligar de um hábito, especialmente de um vício (prejudicialidade).

Por se tratar de conduta que compromete os elementos do dolo – cognitivo ou intelectual [representação] e volitivo – (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001193-87.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE, V.U., j. 02/09/2019, p. 13/14), a clara ofensividade (gravidade) e periculosidade da conduta, independentemente da quantidade da droga, impedem, por assim reconhecer (STF – 2ª Turma – HC 115.246/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28/05/2013), a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, da parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas, LD), não cominou pena privativa de liberdade para o crime de porte ou cultivo ilícitos de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput e § 1º, da LD), cujo preceito secundário passou a cominar medidas educativas (novatio legis in melius).

As medidas educativas, atendendo-se aos critérios dos arts. 42 da LD e 59 do CP (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e a Defesa.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto infracional processado e julgado – Porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28 da LD): I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação de serviços à comunidade; III – comparecimento a programa ou curso educativo –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 14/05/2020

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

*

0004879-24/2017

14/08/2017
08/05/2020
357

*

Reincidência

*

0005561-13/2016
22/11/2016
17/07/2017
358

*

Reincidência

*

0005406-10/2016
22/10/2016
357/358

*

Súm. 444 do STJ

A considerar esse quadro descritivo (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000753-62.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS CORREA, V.U., j. 11/07/2022, p. 03/04 ["O magistrado fez uma tabela informando didaticamente quais condenações utilizou para efeito de maus antecedentes e quais utilizou para efeito de reincidência."]), início a dosimetria.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, os antecedentes são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a medida-base em (i) advertência sobre os efeitos das drogas, (ii) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) meses (art. 28, § 3º, da LD), e (iii) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 2 (dois) meses (art. 28, § 3º, da LD).

Dos antecedentes: A parte ré apresenta dados desabonadores – ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado (v. quadro descritivo) – da vida pregressa.

A reincidência – que significa, em sentido largo (lato sensu), antecedente criminal – pode ser considerada como circunstância judicial, desde que não o seja, simultaneamente, como circunstância agravante (Súmula 241 do STJ).

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ – Terceira Seção – REsp 1.794.854/DF – Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]).

Desconsidero, por outro lado, outras certidões (cf. quadro descritivo), por ser vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré é reincidente (v. quadro descritivo) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP), de modo que fixo a medida provisória em (i) advertência sobre os efeitos das drogas, (ii) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 (dez) meses (art. 28, § 4º, da LD), e (iii) medida

educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 10 (dez) meses (art. 28, § 4º, da LD).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a medida provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP e art. 27 da LD, fixo a MEDIDA DEFINITIVA em (i) advertência sobre os efeitos das drogas, (ii) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 (dez) meses (art. 28, § 4º, da LD), e (iii) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 10 (dez) meses (art. 28, § 4º, da LD).

2.4 Da prestação de serviços à comunidade

A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas (art. 28, § 5º, da LD).

2.5 Da garantia do cumprimento das medidas educativas

Para garantia do cumprimento das medidas educativas aplicadas a que injustificadamente se recuse a parte ré, poderá o Estado-Juiz, de acordo com o art. 28, § 6º, da LD, submetê-la, sucessivamente, a admoestação verbal e multa (art. 29 da LD).

2.6 Dos efeitos da condenação

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, a, do CP, NÃO RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos instrumentos do crime apreendidos com a parte ré (AEA), uma vez que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), não consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito.

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, NÃO RECONHEÇO A PERDA, em favor da União